

1501553-48.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Letícia Pozzi Buassi

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito na modalidade de transporte da substância.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

4ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501553-48.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501553-48.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO HENRIQUE BALDONI FREAZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juíza de Direito: Dra. Maria Letícia Pozzi Buassi

Vistos.

ANTONIO HENRIQUE BALDONI FREAZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, c. c. o art. 61, inc. II, "j", do Cód. Penal, combinados na forma do caput do art. 69 deste mesmo Código.

Consta que no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 10h50min, na "Rodovia Assis Chateaubriand", Km 184, nesta cidade e comarca, transportava e trazia com ele, o réu, para futura entrega a terceiros, uma porção de "maconha", pesando 991,46g, substância esta entorpecente e determinante de dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de portar um aparelho celular, extratos de viagens, documentos pessoais, cartões bancários e R\$ 19,00.

Narra, ainda, a inicial, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, transportava o réu arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver "Custer", calibre 32, municiado com sete cartuchos íntegros, o que fazia sem

autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Policiais militares, em patrulhamento de rotina, abordaram o ônibus da empresa "Viação Motta", com itinerário de Campo Grande/MS à Brasília/DF e, em revista aos passageiros, encontraram as porções do entorpecente no interior da mochila do réu, bem como a arma e as munições nas vestes dele.

Oferecida a denúncia foi o réu notificado e apresentou defesa prévia.

Recebida a denúncia designou-se audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas comuns, uma apontada pela defesa e uma do Juízo.

Após, foi interrogado o réu.

Em debate, o representante do Ministério Público, sustentando demonstradas a materialidade dos fatos e a autoria dos delitos, requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu apontando, em suma, insuficiência de provas a delinear os crimes.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade dos fatos vem comprovada por intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 22/25, a revelar o encontro da droga, do dinheiro, dos documentos pessoais, dos cartões bancários, da mochila, do celular, das passagens rodoviárias interestaduais, do revólver e das munições em tela.

A perícia efetivada na arma e nas munições apontou a eficácia na realização de disparos (fls. 140/144).

Há, ainda, o laudo de constatação de fls. 29/31 e o laudo de exame químico toxicológico de fls. 248/250, concludentes no sentido de se tratar de Tetrahidrocannabinol - THC, a substância encontrada.

O aparelho celular foi vistoriado, constatando-se diálogos relativos ao comércio ilícito e ao transporte da arma (fls. 233/247).

Na fase administrativa exerceu o réu a prerrogativa constitucional de permanecer calado.

Em Juízo, confirmou o réu ter adquirido a arma, ciente da ilegalidade, além da "maconha", que transportava quando passageiro no ônibus. Apontou inexistir intuito de comércio da droga, mas de uso.

Luciano Pimenta, motorista do ônibus, presenciou a localização do tóxico e da arma na bagagem pertencente ao réu, passageiro.

Contam os policiais terem vistoriado as bagagens do ônibus da empresa "Motta", localizando-se, em revista pessoal ao réu, a arma municada, além de, na mochila de propriedade dele, a porção de "maconha". Para tais testemunhas, admitiu o réu a pretensão de transportar a droga até Brasília, onde a negociaria, bem como ser o revólver destinado à entrega para "Guilherme", na capital Federal.

Vale lembrar que o fato de agentes que participam de diligências serem testemunhas sobre estas, torna o relato apresentado mais rico em detalhes e, por isso, mais digno de fé.

No caso em tela as declarações apresentaram-se de forma harmônica e coesa com o restante da prova, razão pela qual não podem ser desconsideradas, inexistindo qualquer motivo para que quisessem os policiais incriminar o réu ou forjar os crimes.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas, em juízo, por policiais. Neste sentido o Supremo Tribunal Federal: "o valor do depoimento pessoal dos servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP, rel. Min. Celso de Mello, DJe 14.03.2011).

A testemunha ouvida em nome da defesa nada acrescentou ao deslinde da questão. Importante consignar ser grande a quantidade de droga apreendida em comparação à condição financeira do réu, que não comprovou relação de emprego, sendo o transporte do entorpecente, com intuito de auferir rendimentos, medida impositiva na situação.

Como não se produziu prova a contrariar o já citado auto de exibição e apreensão, o tráfico é consequência lógica das provas colhidas.

Dessa forma, verifica-se não existirem apenas indícios de prova, mas sim clareza e harmonia entre elas, no sentido de evidenciarem ter o acusado praticado o tráfico ilícito na modalidade de transporte da substância.

Contudo, aponta a Jurisprudência dos Tribunais não ser necessária a prova efetiva do tráfico para a formação do Juízo de certeza, bastando a comprovação, pelos elementos que cercam o agente, da prática de um dos verbos nucleares do tipo penal. Confira-se: "(...) o crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes." (STJ, REsp 1.384.292/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 10/03/2020).

A unanimidade da prova revelou, ainda, a ocorrência da causa de aumento da pena relativa ao fato de ter o réu transportado o tóxico entre Estados da Federação. Além disso, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabia à defesa a prova da existência de registro válido da arma e da munição, bem como de autorização para o réu mantê-las sob guarda, o que não aconteceu, logo, outra explicação não há, exceto ter o réu praticado o crime em estudo.

Assim, a análise das provas aponta, com a certeza necessária, ter tido o réu, sob guarda, arma e munições sem o devido registro.

Não há como consentir que o réu se valha de meios ilegais, fazendo uso irrestrito de arma, como forma de garantir a própria segurança e de familiares. Tinha o acusado a alternativa de agir dentro da legalidade, mediante aquisição de arma de fogo registrada, com a devida documentação e autorização para o porte.

Por fim, vale observar que as finalidades da agravante prevista no art. 61, inc. II, "j", do Cód. Penal, são a proteção da sociedade, bem como punição mais rigorosa da conduta de quem, valendo-se das facilidades do contexto calamitoso, pratica delitos.

In casu, não havendo nexo causal entre a situação de pandemia e a conduta do réu, é de rigor o afastamento da mencionada agravante. Nesse sentido: "Primeiramente, faz-se necessário afastar a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia do COVID-19." (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel. Andrade Sampaio, 12.02.2021).

Convencida da responsabilidade penal do réu, passo a individualizar as penas.

- Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da elevada quantidade de tóxico em transporte, e da personalidade do réu, voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 180/181.

Verificada a reincidência (fls. 180/181), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Com foco na causa especial de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei n.º

11.343/06, pois o tráfico aconteceu entre Estados da Federação, elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

- Art. 14, caput, da Lei 10.826/03:

Tendo em vista os elementos norteadores do art. 59 do Cód. Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por ostentar personalidade do réu voltada à prática criminosa, conforme apontamentos contidos na certidão de fls. 180/181.

Verificada a reincidência (fls. 180/181), incide a circunstância agravante contida no art. 61, inc. I, do Cód. Penal, que se compensa com a confissão da autoria, circunstância atenuante contida no art. 65, inc. III, "d", do Cód. Penal, permanecendo inalterada a pena..

Em face do caput do art. 69 do Cód. Penal, a pena totaliza 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão e pagamento de 804 (oitocentos e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado (art. 1º, § 1º, da Lei n.º 11.464/07).

Destaco que quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, já se observou o período de prisão provisória, nos termos do § 2º do art. 387 do Cód. de Proc. Penal.

O fato de ter o réu respondido encarcerado à instrução do feito não implica, com a prolação desta sentença, na concessão de regime menos gravoso. Neste sentido:

"(...) PENA. DETRAÇÃO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ART. 387, § 2º, DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 12.736/12. FIXAÇÃO A SER EFETUADA PONDERANDO-SE CONJUNTAMENTE O QUANTUM DA PENA APLICADA COM AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS PREVISTAS NOS ARTS. 33, § 3º E 59 DO CP. ENTENDIMENTO. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença". (TJSP, Apelação Criminal nº 1500199-27.2019.8.26.0407, Rel. Des. Grassi Neto, 9ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/11/2020). Ainda: "Descabe, igualmente, pleitear aqui regime prisional mais brando com base na atual redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o que ora se destaca, quer à luz do invocado princípio da suficiência da sanção, quer porque a consideração do tempo de prisão provisória não prescindiria de demonstração cabal de bom comportamento carcerário e de condições subjetivas favoráveis, tal como se exige para a avaliação do cabimento de progressão. Se assim não fosse, ficaria ferida de morte a lógica do sistema penal. E tal demonstração não existe nos autos." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500128-92.2021.8.26.0559, Rel. Fátima Gomes, 9ª Câmara de direito Criminal, julgado em 31.03.2022).

Deixo de aplicar o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque a quantidade da droga apreendida, a pluralidade de delitos e a reincidência, indicam dedicar-se o réu à atividades criminosas, já que ausente comprovação de atividade laborativa.

Nesse sentido a doutrina: "de mais a mais, tem-se decidido que apreensão de grande quantidade de drogas (bem como a diversidade da natureza dos entorpecentes encontrados), a depender das peculiaridades do caso concreto, é circunstância hábil

a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas e, conseqüentemente, a impedir a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porque indica maior envolvimento do agente com o mundo do narcotráfico, ainda que ele seja primário e não possua maus antecedentes. Dessarte, a priori, a circulação de expressiva quantidade de entorpecentes pelo agente evidenciará sua habitualidade delitiva e, por isso, fundamentará o afastamento da causa de diminuição de pena." (MASSON, Cleber; MARÇAL, Vinicius, Lei de Drogas: aspectos penais processuais. 2021, p. 107).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A elevada quantidade de drogas apreendida é circunstância que permite aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas. 3. A despeito de, no julgamento do REsp n. 1.773.834/ES, a Sexta Turma ter ressaltado que a diretriz fixada comporta prova em sentido contrário, no caso, a Defesa não se desincumbiu desse ônus, pois não há qualquer indicação nos autos que afaste a responsabilidade do Acusado acerca da apreensão de 41,820kg de cocaína e 10,240kg de pasta base do mesmo entorpecente. 4. O redutor previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastado com base não apenas na quantidade de droga apreendida e na forma de acondicionamento, pois as instâncias ordinárias também mencionaram outras circunstâncias do caso concreto aptas a justificar a não concessão da citada benesse e a confirmar que a conduta praticada pelo Réu não é algo casual e isolado, quais sejam; "transporte de droga típico de uma organização com vínculo internacional poderosa, a qual contou com uma teia de colaboradores, sendo importante destacar que o plano arquitetado foi muito bem elaborado e esse tipo de negociação certamente envolve diversas pessoas, e não apenas o transportador da cocaína, nem tampouco o funileiro que a escondeu no veículo, mas também capitalizados compradores e fornecedores." (STJ, AgRg no AREsp 1799093/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021) O valor unitário do dia-multa é o mínimo legal, considerada a situação econômica do acusado (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e condeno ANTÔNIO HENRIQUE BALDONI FREAZA, R.G. n.º 71.903.810, a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 804 (oitocentos e quatro) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, por ter infringido o art. 33, caput, c. c. o art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, e o art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, combinados na forma do caput do art. 69 do Código Penal.

Não poderá o réu apelar desta sentença em liberdade, nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.464/07.

Ainda que assim não fosse, em sendo necessária a prisão no correr da instrução do feito, a prolação desta sentença condenatória apenas reforça os motivos ensejadores do afastamento do réu do convívio social, por garantia da ordem pública.

Recomende-se o réu no presídio onde se encontra, expedindo-se mandado de prisão, se necessário.

A pena pecuniária será atualizada a partir da data do fato, uma vez que a correção monetária não apresenta nenhum plus, mas sim tentativa de reposição do poder aquisitivo da moeda.

Força concluir ainda, que a multa não corrigida perde o caráter aflitivo, tornando inútil a imposição, inatendidas as finalidades da sanção penal de punição, dissuasão e reeducação do delinquente.

Observados o art. 63 da Lei nº 11.343/06 e o art. 91, inc. II, "b", do Cód. Penal, DETERMINO O PERDIMENTO do celular e do dinheiro, pois obtidos em razão do comércio ilícito, conforme prova colhida. Para tanto, oficie-se ao FUNAD.

Após o trânsito em julgado, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial para o fim de destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA